



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/84/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט-שילוני

1	מאיר דורית, ת.ז. 053938627	תובעים
2	מאיר אלעד אליעזר מצדה 82, אשדוד	
3	מאיר יונתן שמעון מצדה 82, אשדוד	
4	מאיר אורטל מצדה 82, אשדוד	
באמצעות ב"כ: עו"ד צבר אורלי רח' הרצל ת.ד. 528 מיקוד 80300, אופקים טל': 0522570850		

נגד

1	אילוז שגיא, ת.ז. 037719671	נתבעים
2	אילוז ליאת	
באמצעות ב"כ: עו"ד אביחי רביבו ו/או עו"ד אהרון חזן סחרוב דוד 19, ראשון לציון		

פסק דין

א. רקע עובדתי והשתלשלות ההליך:

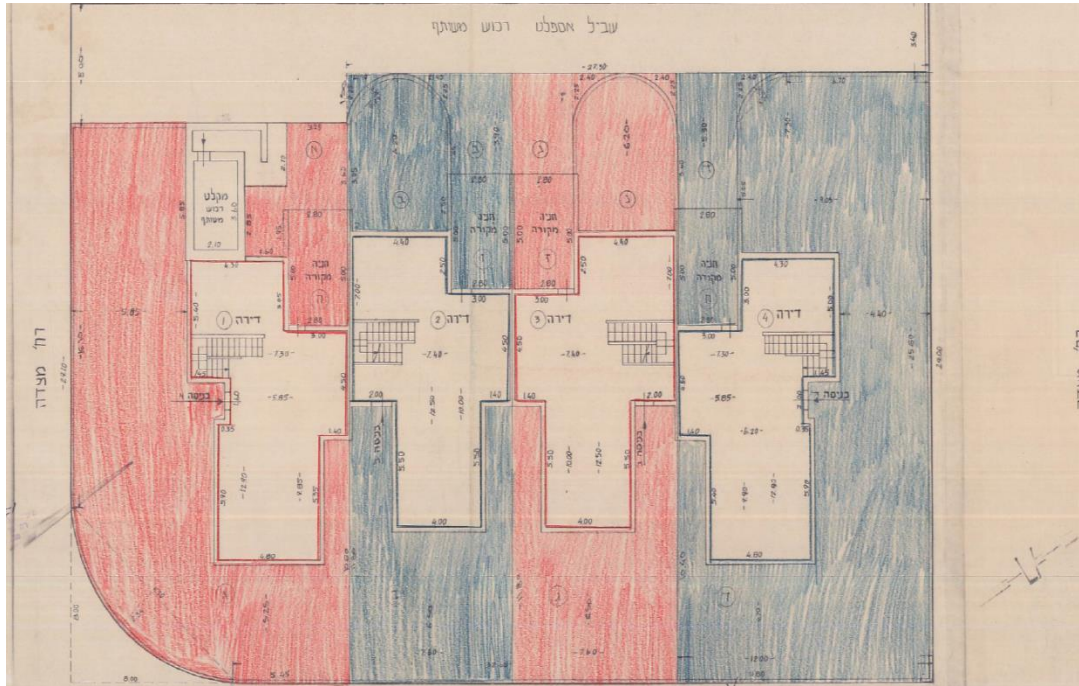
1. עסקינן בבית המשותף ברחוב הר מצדה 82 אשדוד הידוע כגוש 2192 חלקה 79 (להלן – **"הבית המשותף"** או **"הבית"**). הבית מורכב מארבע חלקות משנה המהוות ארבע דירות השוכנות זו לצד זו בטור, ורכוש משותף אשר כולל, בין היתר, מקלט ושביל אספלט שעובר בצדה המערבי של החלקה (להלן – **"שביל הגישה המשותף"**). להלן קטע מתוך תשריט הבית המשותף שנועד להמחיש את תיאור החלקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/84/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



2. התובעים הם בעלי הזכויות בחלקת משנה 1, והנתבעים הם בעלי הזכויות בחלקת משנה 4. דירת הנתבעים נרכשה ממר זאב וגב' מדאה קימלמן (להלן – **קימלמן**) בשלהי שנת 2015.
3. ביום 05.01.16, הגישו הנתבעים בקשה למתן היתר בניה שעיקרה היה הרחבת הדירה שבבעלותם לשם בניית ממ"ד. כעולה מן הבקשה, הממ"ד תוכנן להיבנות בשטח חניה מקורה שהוצמד לדירת הנתבעים (ראה ח' בתשריט הבית). כן עולה, כי תחת אותה חניה מקורה סומנו בתכנית שתי חניות: האחת, בקרקע המוצמדת לדירת הנתבעים המהווה רכוש פרטי (ראה ד' בתשריט הבית) והשנייה, בשטח שביל הגישה המשותף הסמוך לדירתם. כמו כן, על גבי התכנית מופיעות שתי חתימות תחת הכותרת "אין התנגדות לבניה המוצעת": האחת, של גב' פלורי תורג'מן – בעלת הזכויות בחלקת משנה 2 (להלן – **תורג'מן**) והשנייה, של גב' שרה טרזיים – בעלת הזכויות בחלקת משנה 3 באותה העת (להלן – **טרזיים**). נוסף על חתימות אלה, הוצג מסמך ריק אשר נושא את חתימת התובעת 1 תחת התיאור "אין התנגדות לבניה המוצעת" מיום 27.12.15 (נספח ה' לכתב ההגנה).
4. יצוין כי ביום 02.02.17 הגישו הנתבעים תכנית מתוקנת במסגרתה נתבקשו מספר שינויים להיתר. לענייננו, בתכנית זו מופיע השטח המשותף שבמחלוקת תחת התיאור "בטון מוחלק בשיפוע" ואין חתימה של מי מבעלי הדירות על השינוי המבוקש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/84/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. במסגרת ביצוע העבודות הגביהו הנתבעים את החומה אשר תוחמת את החלקה בגבולה הצפוני באמצעות גדר אלומיניום, יצקו משטח בטון מוחלק על גבי חלקו של שביל הגישה המשותף הסמוך לדירתם והתקינו מלפניו שער חשמלי המיוחד למעשה את אותו חלק משביל הגישה המשותף לשימוש הפרטי. סיפוח חלק זה משביל הגישה המשותף לדירת הנתבעים הוא העומד בבסיס התביעה דנן. יצוין כי מדובר בשטח של כ-40 מ"ר.
6. בחלוף שנה מסיום העבודות ביקשו הנתבעים לתקן את צו רישום הבית המשותף. לצורך כך ערכו הנתבעים תצהיר עליו חתמו גב' תורג'מן, מר טל אזוגי אשר לפי הנטען שימש בעת ההיא מיופה כוחם של בני משפחת טרויים ובנה של התובעת 1 - התובע 3. התצהיר נוסח באופן הבא: **"הריני להצהיר כי מהות התיקון בתשריט לתיקון הבית, הינו התאמת שטחי בית מס' 4 להיתר החדש והצמדת שטח גישה לחניה ליחידה 4 כפי שיפורט בסעיף 4 להלן".** בסיפה סעיף 4 נאמר **"... ו-קרקע לחניה וגישה לחניה מסומנים באותיות יט בשטח של 42.45 מ"ר בצבע תכלת, והם יוצמדו ליחידה הרישומית החדשה 79/4".** (נספח ו' לכתב ההגנה).
7. למען שלמות התמונה אציין כי בתחילה הוגשה התביעה על-ידי התובעת 1, אלא שבדיון המקדמי שנערך ביום 28.05.18 התברר כי זו מחזיקה רק חלק מן הזכויות בדירתה והיתר מוחזקות בידי התובעים 2-4. על כן, ועל מנת להביא להכרעה יעילה ושלמה בכל השאלות שבמחלוקת, הוריתי בהחלטתי מאותו יום על צירופם של התובעים 2-4 כצד להליך.
8. עוד אציין, כי ביום 24.07.18 ביקרתי בבית המשותף וצפיתי באותו חלק משביל הגישה המשותף אשר סיפחו לעצמם הנתבעים באמצעות התקנת השער החשמלי, וכן במשטח הבטון אשר יצקו על גבי שטח זה ועל גבי שטח סמוך. כמו כן, מצאתי שני רכבים השייכים לתובעים אשר חונים האחד בכניסה לשביל הגישה המשותף במאוזן, והשני בסמוך למקלט המשותף, כשחלקו על גבי שטח הרכוש המשותף וחלקו על שטח שהוצמד לדירתם. להתרשמותי, בלב המחלוקת ניצב אותו שער חשמלי המיוחד חלק משביל הגישה המשותף לדירת הנתבעים. ניסיון להביא את הצדדים להסכמות בדבר השימוש בשטח המשותף מושא המחלוקת לא הסתייע והתיק נקבע לשמיעת ראיות.

ב. תמצית טענות הצדדים:

9. התובעים טענו כי למן היום בו רכשו הנתבעים את דירתם הובהר להם כי שביל הגישה מהווה רכוש משותף שאין לגביו היתר לשימוש ייחודי. לשיטתם, סיפוח אותו חלק משביל הגישה המשותף לדירת הנתבעים טעון היה הסכמה של כל בעלי הדירות אלא שהנתבעים, כך נטען, לא טרחו לברר מיהם בעלי הזכויות בבית וממילא לא קיבלו הסכמת כולם לצורך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/84/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כך. בהקשר זה טענו התובעים כי השינויים שהציגו בפניהם הנתבעים כללו אך שינויים שבמבנה הדירה ובשטחים הצמודים לה, וכי לא דובר ולא הוסכם על עריכת שינויים בחלקי הרכוש המשותף אגב כך. לפיכך נטען, כי חתימת התובעת 1 על גבי מסמך ריק, כמו גם חתימתן של גב' טרזיים וגב' תורג'מן על תכנית ההיתר ועל התצהיר שנלווה לבקשה לתיקון צו רישום הבית המשותף, אינן מהוות הסכמה מפורשת לשם הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף והצמדתם לאחת הדירות וכי אלה הושגו במרמה. מכל מקום נטען כי בהעדר חתימתה של התובעת 4 אשר מחזיקה ב-1/12 מזכות הבעלות בחלקת משנה 1, לא היו רשאים הנתבעים לספח לעצמם חלק משביל הגישה המשותף באמצעות התקנת השער החשמלי, ולא לבצע את יתר השינויים שבוצעו בחלק זה.

10. מן העבר האחר טענו הנתבעים כי הסכמת בעלי הדירות כולם ניתנה כבר בשלב הבקשה להיתר בנייה, לאחר שהוצגו בפניהם השינויים המבוקשים והשפעתם על חלקי הרכוש המשותף. בתוך כך טענו הנתבעים כי אף על-פי שלא נדרשו להסכמת כל בעלי הדירות פעלו מתוך שכנות טובה וביקשו הסכמה גם מאת התובעת 1. לעניין זה הפנו הנתבעים לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין") סיפא שעניינו ברוב הדרוש לשם הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה שתכליתה בניית ממ"ד. נטען כי עם השלמת הבניה ולקראת תיקון צו רישום הבית המשותף, חזרה בה התובעת 1 מהסכמתה. הסיבה, כך נטען, תנאי שהעמידה התובעת 1 לפיו הנתבעים לא יתנגדו להצמדת המקלט המשותף לדירתה אשר התברר בדיעבד כבלתי ישים, וזאת לאחר שנטלו הלוואות והושקעו כספים רבים בהסתמך על ההסכמות שניתנו. לאור זאת נטען כי בהינתן אותן הסכמות ובשים לב לחלוף הזמן מאז החלו העבודות ועד המועד בו הוגשה התביעה, הרי שאין מקום להורות כיום על השבת מצב הדברים בבית לקדמותו. לצד זאת טענו הנתבעים, כי מיום שהוקם הבית המשותף היה השטח המשותף שבמחלוקת בשימוש הבלעדי של בני משפחת קימלמן מבלי שהובעה לכך התנגדות כלשהי מצדם של יתר בעלי הדירות. לפיכך סבורים הנתבעים כי יש להחיל על נסיבות העניין את דוקטרינת ההשתק הקנייני, שלפיה התובעים מנועים כיום מלהעלות טענות בעניין שימוש ייחודי בחלק זה של הרכוש המשותף. הנתבעים הוסיפו כי זה שנים שהתובעת 1 עושה שימוש ייחודי במקלט ובשביל הגישה המשותף לצרכי חניה מבלי שקיבלה על כך הסכמת יתר בעלי הדירות וכי התביעה אינה אלא ניצול לרעה של זכות הפניה לערכאות וביטוי לחוסר תום לב. צוין כי לצורך יישוב הסכסוך בדרכי שלום פנו הנתבעים לשמאי אשר יעריך את דמי האיזון המגיעים לתובעים בגין סיפוח הרכוש המשותף אלא שהתובעים בחרו לסרב לאפשרות זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/84/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. דיון והכרעה:

11. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ועיינתי בחומר הראיתי המונח לפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה וכי על הנתבעים להסיר את השער החשמלי שהתקינו על גבי שביל הגישה המשותף. להלן טעמי.

12. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כי:

"62. (א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות." (ההדגשה אינה במקור)

13. בד בבד קובע סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין כי:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה." (ההדגשה אינה במקור)

14. על יסוד כך קובעת הפסיקה כי אף תפיסת חזקה ייחודית בשטח הרכוש המשותף טעונה הסכמת כל בעלי הדירות:

"תפיסת חזקה בלעדית על-ידי בנייה ב"רכוש המשותף", המיועד לשמש את כל "בעלי" הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מה"רכוש המשותף" משאר "בעלי" הדירות, ו"ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם" ע"א 504/68 [3], בעמ' 692; ע"א 31/70 [4], בעמ' 391)... זכות "השייכות לכמה שותפים ואינה מתייחסת לענין שימושי רגיל שכולם נהנים ממנו בדרך של שיגרה, אין אחד השותפים יכול ליטול אותה או חלק ממנה לעצמו ולהדיר את השותפים האחרים מהנאתם ממנה שלא בהסכמתם" (ע"א 136/63 [5], בעמ' 1726 (ע"א 698/85 יהודה בן צור נ' נעים ששון (פורסם בנבו, 23.07.87)).

ראה גם: ע"א 31/70 עזרא כהן נ' חיים שמאי (פורסם בנבו, 28.09.70).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/84/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. אשר לאופייה של ההסכמה הנדרשת נקבע כי זו אינה טעונה מסמך בכתב, ואף הסכמה בעל פה הסכמה היא ובלבד שהיא ברורה, מפורשת וקונקרטית ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע או על דרך התנהגותם של בעלי הדירות במרוצת הזמן (דנ"א 2415/01 **חברת פליצה ראובן בע"מ נ' גב' ציפורה סופיוב** (פורסם בנבו, 30.05.01); ע"א (חי) 13721-05-16 **אליהו גבאי נ' יאיר הקש** (פורסם בנבו, 05.10.16) (להלן – **עניין הקש**); ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול** (פורסם בנבו, 08.07.82); ע"א 9502/06 **רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל** (פורסם בנבו, 07.08.07)).

16. הנה כי כן, לצורך סיפוח חלק משביל הגישה המשותף לדירתם נדרשו הנתבעים להסכמתם של כל בעלי הדירות בבית. הסכמה כאמור לא ניתנה, ודי אם אפנה בהקשר זה לעובדה כי מצבת בעלי הזכויות בבית כוללת, בין היתר, את התובעת 4 לגביה אין חולק כי לא נתנה הסכמתה לכך. לעניין זה העידה התובעת 4 בחקירתה כי:
ש: בסעיף 49 את טוענת שהשער הותקן ללא חתימות כלל.
ת: נכון כי אני לא חתמתי. יש לי זיקה לשטח הזה.

...

ש: אני אומר לך שהיתה הסכמה בעל פה ובכתב.

ת: אני לא נתתי לו הסכמה."

(עמ' 14-15 שורות 41-42 ו- 7-8 (בהתאמה) לפרוטוקול הדיון מיום 01.11.18).

17. עובדה זו נלמדת אף מעדותו של הנתבע 1 אשר מסר בחקירתו כי:
ש: אני מפנה אותך לסעיף 11 לתצהירך. אתה כותב שם שכל דיירי הבית כולם חתמו על הסכמתם לשינויים שנעשו בבית בבניה ואין להצמדת שטח לרכוש המשותף.
ת: נכון.

ש: מי זו באולם בית המשפט?

ת: אורטל.

ש: אתה החתמת אותה על משהו פעם?

ת: לא.

ש: בעל פה, בשמועה?

ת: לא.

(עמ' 17-18 שורות 43-48 ו- 1-3 לפרוטוקול הדיון מיום 01.11.18).

18. אף באשר לתובע 2 לא מצאתי עדות לכך שהסכים לשינויים כלשהם בשטח הרכוש המשותף, לבטח לא הסכמה מפורשת כמתחייב בנסיבות העניין. עם זאת, כיוון שהועלו טענות באשר לכשרותו המשפטית, איני מוצאת לנכון להידרש לכך בהרחבה.

19. למעלה מן הצורך אוסיף, כי ספק רב בעיניי אם ניתן לראות בחתימה על בקשה להיתר בניה הסכמה מפורשת להוצאת חלקים מן הרכוש המשותף והצמדתם לאחת הדירות. כמפורט



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/84/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מעלה, הלכה פסוקה היא שהסכמה בדבר הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, ואין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדוקנות, כאשר בכל מקרה של ספק הנטייה היא לשלול את ההצמדה (ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם (פורסם בנבו, 02.03.80)). חתימתן של גב' תורג'מן וגב' טרזיים על תכנית ההיתר עשויה אמנם להעיד על הסכמתן בדבר תוספת בנייה לדירת הנתבעים, ואולם אין בה, כשלעצמה, ללמד על הסכמה בדבר הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף באופן מפורש ומסוים כמתחייב בנסיבות העניין (לעמדה דומה ראה: ת"א (חי') 1636-03-15 דוד רומנו נ' גלי רלר (פורסם בנבו, 27.12.17)).

לכך יש להוסיף כי לא מצאתי שניתן להסתמך על חתימת התובעת 1 על גבי מסמך ריק.

20. מכל מקום, בהעדר הסכמת כל בעלי הדירות בבית, לא היו רשאים הנתבעים לספח לעצמם חלק משביל הגישה המשותף לדירתם באמצעות התקנת שער חשמלי או בכל דרך אחרת.

21. הנתבעים מצדם סבורים כי בנסיבות העניין די היה בהסכמת רוב בעלי הדירות לצורך סיפוח אותו חלק משביל הגישה המשותף לדירתם, והם מפנים בהקשר זה לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. בהתאם לסעיף זה, די ברוב של ששים אחוזים מבעלי הדירות בבית לצורך הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם הרחבת אותה דירה בדרך של תוספת ממ"ד:

"71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם ששים אחוזים מהדירות.

22. בהקשר זה טענו הנתבעים כי מאחר שתנאי לקבלת ההיתר היה סימון שני מקומות חניה חלף אותה חניה מקורה שעליה תוכנן להיבנות הממ"ד, "נסוגה החניה כ-5.8 מטרים לכיוון גבול החלקה המזרחי" (סעיף 33 לכתב התביעה). טענתם כי סיפוח אותו חלק משביל הגישה המשותף מהווה חלק בלתי נפרד מהרחבת הדירה לצורך בניית ממ"ד ולפיכך די היה בהסכמת ששים אחוזים מבעלי הדירות, איננה מקובלת עליי ודינה להידחות.

23. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק המקרקעין כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". לעניין זה מובא בספרו של המלומד א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק ג', עמוד 222) כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/84/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך זירת המבקש" (ההדגשה אינה במקור).

24. ואולם, הממ"ד בנסיבות העניין תוכנן להיבנות על שטח חניה מקורה המהווה חלק מדירת הנתבעים ולא חלק מן הרכוש המשותף (ראה ח' בתשריט הבית). כלומר, אין מדובר בהרחבה אשר הצריכה, במישורין או בעקיפין, הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף, וההנחה שלפיה מדובר בהמשך טבעי או פועל יוצא של אותה הרחבה אינה אלא הנחת המבוקש.

25. הדרישה מצד הוועדה המקומית אינה יכולה להוות תחליף להסכמתם המפורשת של כל בעלי הדירות בדבר הוצאת חלק משביל הגישה המשותף והצמדתו לדירת הנתבעים. להווי ידוע, כי מלאכתה של הוועדה המקומית מתמצית בהיבטים תכנוניים בלבד. הוועדה אינה דנה ואינה עוסקת בסוגיות קנייניות (בג"ץ 305/82 יוסף מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז המרכז (פורסם בנבו, 26.01.84). הזכות לבקש היתר לאחד מבעליו של נכס אין בה כדי לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של בעלים אחרים של אותו נכס. היטיב לתאר זאת המלומד מיגל דויטש בספרו 'קניין' (כרך א' עמוד 695):

"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין..."

26. לפיכך, אין ללמוד מן הבקשה להיתר בניה האם עמדה לנתבעים זכות קניינית באותו חלק משביל הגישה המשותף הצמוד לדירתם (לעמדה דומה ראה (מפקחת על רישום מקרקעין) 115/09 פרטוש שמעון נ' פרנקנטל שרה (פורסם בנבו, 08.07.10)) ולפי שהיתר לחוד וזכויות קנייניות לחוד, סיפור אותו חלק משביל הגישה המשותף מחייב היה קבלת הסכמה מפורשת מצדם של כל בעלי הדירות בהתאם לסעיף 62(א) לחוק המקרקעין (ראה והשווה: ת"א (ת"א) 57330-11-15 שאול נאקי נ' שלמה סלמן (פורסם בנבו, 14.05.18).

27. אשר לטענת הנתבעים בדבר השתק קנייני. כנזכר, בעניין זה טענו הנתבעים כי מאז שהוקם הבית המשותף היה השטח המשותף שבמחלוקת בשימושם הבלעדי של בני משפחת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/84/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קימלמן בלא שקמה לכך התנגדות מצד מי מבעלי הדירות. לפיכך, סבורים הנתבעים כי אף אם יוכח כי לא ניתנה הסכמת בעלי הדירות כדין, ההחזקה מרובת השנים מצד בני משפחת קימלמן מלמדת כי לקימלמן – ובהמשך לנתבעים – ניתן רישיון לשימוש ייחודי בחלק זה של הרכוש המשותף, וכי התובעים מנועים כיום להביא לביטולו מכוח עיקרון ה"השתק הקנייני". טענה זו דינה להידחות, אף היא.

28. מעדותו של מר קימלמן עלה כי בני משפחת קימלמן אכן נהגו להחנות את רכביהם בשטח הרכוש המשותף מושא המחלוקת, ואולם אף לשיטתם של אלה אין מדובר בשטח שיוחד לשימוש הפרטי בלבד, כי אם בשטח משותף. לדברי קימלמן בחקירתו, מכירת הדירה לנתבעים התבססה על מסמכי רישום הבית המשותף בהם מופיע שביל הגישה כרכוש משותף ומבלי שהוצג אותו חלק משביל הגישה הסמוך לדירה כשטח שלגביו ניתנה רשות לשימוש ייחודי (עמ' 13 שורות 27-30 לפרוטוקול הדיון מיום 01.11.18). כך עלה גם מחקירתה של התובעת 1 אשר מסרה בהקשר זה כי:

ש: קימלמן חנה שם כל השנים?

ת: לרוב הם השתמשו. הם היו אנשים נפלאים. ולפעמים אני הייתי מחנה שם. לעיתים לא קרובות אבל גם אני חניתי שם.

(עמ' 4 שורות 7-9 לפרוטוקול הדיון מיום 01.11.18).

29. לא השתכנעתי כי ניתנה לקימלמן רשות לשימוש ייחודי בשביל הגישה המשותף ואין די בעובדה כי הלה נהג להחנות את רכבו בחלק זה כדי ללמד על ויתור מצד שאר בעלי הדירות על זכויותיהם הקנייניות בשטח זה (עניין הקש).

30. זאת ועוד, רשות שלא ניתנה בעדה תמורה נתפסת כ"זכות אישית" שאינה ניתנת להעברה והיא באה אל קצה עם העברת זכותו של בר הרשות במקרקעין לאחר (ת"א 12336/98 יעל סיאס נ' אביעד שר שלום (פורסם בנבו, 20.01.00). לפיכך, אף אם ניתנה לקימלמן רשות לשימוש ייחודי בשביל הגישה המשותף, הרי זו פקעה עם העברת הזכויות בדירה לידי הנתבעים.

31. טרם סיום אדגיש כי לא נעלמה מעיניי טענת הנתבעים בדבר שיהוי בהגשת התביעה. אזכיר, כי בעניין זה טענו הנתבעים כי התביעה הוגשה בחלוף שנתיים מאז הוחל בביצוע העבודות ולאחר שנטלו הלוואות והושקעו כספים רבים. לדבריהם, אין זאת אלא חוסר תום לב וניצול לרעה של זכות הפניה לערכאות. לכך לא מצאתי כל התייחסות בסיכומי התובעים. עם זאת, אף כי בהתנהלות התובעים בהקשר זה אני מוצאת משום טעם לפגם, לא השתכנעתי כי השיהוי בנסיבות העניין מצדיק פגיעה בזכויותיהם הקנייניות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/84/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ד. סוף דבר:

32. דין התביעה להתקבל בחלקה. הנתבעים יסלקו את השער החשמלי שהתקינו על גבי שביל הגישה המשותף בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.

33. לאור תוצאה זו, ובשים לב לכלל נסיבות העניין, איני מוצאת מקום להורות על פירוק משטח הבטון אשר יצקו הנתבעים על גבי אותו חלק משביל הגישה הסמוך לדירתם ועל פירוק הגדרות אותן העמידו הנתבעים בגבול החלקה, שכן באלה אין כדי לפגוע בזכויותיהם של התובעים.

34. כמו כן, אני קובעת כי הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים בסך של 3,000 ש"ח. סכום זה ישולם לתובעים בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 28 נובמבר 2019, ל' חשון תש"פ, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין